

0001208-76.2022.8.26.0348

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... (bar de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001208-76.2022.8.26.0348 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001208-76.2022.8.26.0348

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA BEATRIZ GOMES DUARTE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

ANA BEATRIZ GOMES DUARTE e FERNANDO GABRIEL ALVES ANDRADE foram denunciados por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 10 de janeiro de 2022, por volta das 17h05min, na Travessa Ubajara, 70 - Jardim Oratório, nesta cidade de Mauá, a acusada, para fins de tráfico, expôs à venda e vendeu substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, descritas no auto de exibição e apreensão (fls. 17-8) e laudo de constatação (fls. 19-21), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia, a acusada Ana Beatriz foi citada (fl. 183) e apresentou resposta à acusação.

O réu Fernando foi julgado nos autos principais nº 1500107-33.2022.

Durante a instrução, a testemunha arrolada pelas partes foi devidamente inquirida. Por fim, interrogou-se a ré.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, enquanto a Defesa requer a nulidade da instrução por inobservância ao procedimento relativo ao acordo de não persecução penal. No mérito, pugna pela absolvição ante a ilicitude da prova produzida ou, ao menos, a aplicação da pena nos patamares mínimos, com o reconhecimento da confissão, da menoridade relativa e do tráfico privilegiado, a fixação de regime penitenciário inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Malgrado o esforço argumentativo do douto Defensor Público, a preliminar levantada não se sustenta. A questão atinente ao acordo de não persecução penal já foi devidamente afastada no momento oportuno (fls.205-11).

No mérito, a acusação procede.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03-7), boletim de ocorrência (fls. 13-6), auto de exibição e apreensão (fls. 17-8), laudo de constatação (fls. 19-21), fotografias (fls. 40-1), laudos de exame químico-toxicológico (fls. 153-5 e 220-6) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

Interrogada, em solo policial (fl.12) e em juízo (mídia digital), a ré manifestou-se.

O guarda municipal Leovigildo, na fase administrativa (fl.10), historiou que: (sic) "junto do meu colega de corporação, Valdeir Monteiro Da Silva, no momento dos fatos estávamos em serviço na viatura 90060 e passamos a patrulhar as imediações da Travessa Ubajara, no Jardim Oratório, nesta cidade de Mauá, porque pelo teor de uma denúncia anônima, que nos foi dirigida via CECOM, lá haveria um casal praticando a traficância; na denúncia, foi explicado que tais pessoas eram um rapaz moreno, que vestia blusa preta, e uma mulher baixinha que tinha os cabelos vermelhos; dizia ainda que o entorpecente por eles vendido era guardado embaixo de umas madeiras existente no local; com base nessas informações, acessamos a referida travessa; no instante em que entramos avistamos um casal ostentando aquelas características citadas na denúncia; o indivíduo do sexo masculino, que foi qualificado como Fernando Gabriel Alves Andrade, logo foi abordado, não tendo conseguido correr; já a menina, que depois foi qualificada como Ana Beatriz Gomes Duarte, saiu em desabalada carreira deixando cair dinheiro e alguns objetos, que em seguida apanhamos e notamos que se tratavam invólucros que aparentavam conterem drogas ilícitas, a qual foi abordada ainda no interior da aludida travessa; além disso, fomos vasculhar as madeiras que haviam ao lado de onde Fernando se achava quando foi abordado; embaixo delas, encontramos uma mochila e dentro dela, descobrimos mais dezenas de invólucros idênticos aqueles derrubados por Ana Beatriz na tentativa de fuga, além de outros tipos de embalagens, que somados, totalizaram 250 (duzentos e cinquenta) invólucros de cocaína (em pó), 572 (quinhentos e setenta e dois) invólucros, também de cocaína, mas na forma de crack, 272 (duzentos e setenta e dois) invólucros de maconha, 7 (sete) comprimidos de Ecstasy e 45 (quarenta e cinco) recipientes envazando lança-perfume, além da quantia de R\$142,00 (cento e quarenta e dois reais); assim, questionamos ambos sobre aquelas substâncias e o dinheiro, ocasião em que Ana Beatriz confirmou serem mesmo drogas ilícitas, bem como que junto de Fernando praticavam o tráfico naquele lugar, embora Fernando

tenha negado essa conduta".

No mesmo sentido o depoimento do guarda municipal Valdeir (fls.08-9).

Em juízo, o guarda Valdeir disse que receberam denúncia via CECOM acerca de um casal que estava praticando o tráfico de drogas na viela. Ao entrarem na viela, viram o casal, a ré correu e o corréu não conseguiu correr porque foi logo abordado. A acusada saiu correndo e jogando dinheiro e entorpecentes pela via pública, mas foi detida. A ré afirmou que estava traficando no local com o corréu. Havia drogas nas vestes da ré, ela retirou do sutiã e dos bolsos. Na denúncia foi informado que ao lado deles havia umas madeiras, local de onde retiravam as drogas e revendiam. Localizaram uma mochila nas referidas madeiras com significativa quantidade de droga. Afirmou que o local é conhecido como ponto de tráfico (mídia digital).

Destaca-se, inicialmente, a ausência de qualquer irregularidade na prisão em flagrante efetuada por guardas municipais, diante do notório estado flagrancial e da autorização prevista no art. 301 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, posicionou-se o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Revisão Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Ajuizamento de ação revisional. Alegada obtenção de provas por meios ilícitos, posto colhidas por guardas municipais. Impossibilidade. Nulidade não verificada. Pedido de absolvição. Mera intenção de reexame dos fatos. Conjunto fático exaustivamente enfrentando. Inexistência de fatos supervenientes a justificar reanálise do conjunto probatório. Ação revisional que não se perfaz em uma terceira apelação. Mérito mantido. Improcedência. [...] Não se vislumbra, in casu, a alegada obtenção das provas por meios ilícitos, porquanto não só os guardas municipais podem efetuar a prisão em flagrante, como qualquer um do povo pode fazê-lo. É o teor do artigo 301, do Código de Processo Penal. Ademais, os guardas municipais responsáveis pelo flagrante delito encontravam-se atuantes nos estritos termos dispostos pela Lei 13.022/2014 que regulamentou a competência atribuída à Corporação pelo artigo 144, § 8º, da Constituição Federal. Com a edição de referida Lei, a guarda municipal, no seu território, pode exercer a polícia ostensiva e auxiliar as forças estaduais e federais na segurança pública. Particularmente, no âmbito do flagrante, destaca-se o artigo 5º, inciso XIV, da Lei 13.022/2014. Embora o preceituado neste artigo ultrapasse os limites previstos no artigo 144, § 8º, da CF, entendemos constitucional a previsão. Afinal, tudo o que se relaciona com o munícipe não deixa de ter relação com a tutela dos bens, serviços e instalações do Município onde reside. Ademais, deixou-se cláusula aberta ao final do parágrafo, "conforme dispuser a lei". Diante disso, a guarda municipal tem hoje, dentro dos limites municipais, o mesmo poder da Polícia Militar. [...]" (TJ/SP, Revisão Criminal nº 2017191-29.2020.8.26.0000, 8º Grupo de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme De Souza Nucci, Data do julgamento: 13/07/2020, Data de publicação: 13/07/2020 - grifo nosso).

APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS Preliminar de nulidade Alegação de incompetência dos guardas municipais para efetuar a prisão em flagrante Descabimento Réu que estava em atitude suspeita Situação de flagrância Legalidade da prisão efetuada por guardas municipais (art. 301 do CPP) Preliminar rejeitada MÉRITO Pleito de desclassificação Impossibilidade Materialidade, autoria e destinação das drogas evidenciadas nos autos Desnecessidade de se surpreender o agente em atos de comercialização Crime de conteúdo variado Condenação mantida PENA Quantidade e variedade de drogas a inviabilizar a aplicação, na fração máxima, do art. 33, §40, da Lei 11.343/06 Abrandamento do regime prisional Desacolhimento, por maioria Preliminar rejeitada e recurso desprovido. (TJ/SP, Apl. Criminal nº 0000508-07.2016.8.26.0544, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 27/06/2017, Data de publicação: 03/07/2017).

No mesmo sentido, há julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Sem razão a defesa também no ponto em que afirma haverem as guardas municipais exorbitado os limites do patrulhamento preventivo, ao agirem como polícia ostensiva. No caso, não se está a reconhecer o policiamento ostensivo das guardas municipais, mas sim a atribuição de funções essenciais à proteção da população local, bem como de bens, serviços e instalações. É possível que, durante o patrulhamento preventivo, destinado à salvaguarda dos sobreditos bens jurídicos, o agente municipal se depare com situação de flagrante delito ou, ainda, que, diante de notícia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, proceda à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estaria desautorizado a agir. A situação de flagrância delitiva legitima a atuação de "qualquer pessoa do povo" a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões. Além disso, a Lei n. 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) prevê, expressamente, como princípio mínimo de atuação das guardas municipais, o patrulhamento preventivo (art. 3º, III) e, não obstante dispositivos da referida legislação sejam objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.156, certo é que, até o momento, não houve nenhuma decisão por parte da Corte Suprema, de maneira que a lei em questão continua em pleno vigor no ordenamento jurídico pátrio. Finalmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, já manifestou entendimento de que o art. 144 da Constituição Federal não estabelece o monopólio da função de investigação criminal à polícia. Destarte, a sua interpretação, vista em conjunto com o art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal, legitima a atuação investigativa por outras autoridades (v. g., AP n. 611/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª T., DJe 10/12/2014). Válida, portanto, foi a atuação das guardas municipais e, por conseguinte, a apreensão de substâncias entorpecentes por elas levada a efeito após a realização de revista pessoal no acusado." (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.715.660 - SP (2017/0324006-0), Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Publicado em 17/02/2020 - grifo nosso).

"[...] Pois bem, do excerto transcrito verifica-se que o acórdão impugnado não destoaria da jurisprudência desta Corte, que entende que a busca e apreensão de drogas efetuada por guardas municipais não padece da eiva suscitada, embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, § 8º. da Constituição da República, sendo o delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator, nos termos do art. 301 do CPP. Precedente. (AgRg no AREsp n. 1.565.524/MS, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 12/12/2019). Ainda nesse sentido: AgInt no AREsp n. 950.569/MS, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/02/2017; e HC n. 525.772/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/10/2019. [...]" (STJ, HC 557934, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Publicado em 17/04/2020).

No mais, descabida a alegação da Defesa quanto à ilegalidade na busca pessoal, uma vez que os guardas municipais que realizaram a abordagem afirmaram que, após receberem informações sobre um casal que estaria comercializando drogas no local, ponto de tráfico, visualizaram a ré em exata correspondência com as características irradiadas pelo CECOM. Não bastasse, Ana Beatriz tentou empreender fuga e dispensou as drogas ao visualizar a equipe, de forma que demonstradas, de forma mais que satisfatória, as fundadas razões para a busca pessoal.

Aliás, esse foi o entendimento do e. Tribunal de Justiça ao analisar a conduta do corréu Fernando em sede de apelação:

"Não há qualquer ilegalidade na atuação dos guardas civis municipais, que realizavam patrulhamento rotineiro, quando receberam informação sobre a prática do tráfico de drogas no local e observaram o comportamento suspeito do réu, em conhecido ponto de tráfico de entorpecentes, e que por isso o abordaram, sobreindo a apreensão de porções de "crack", de cocaína, de maconha, de "ecstasy" e de "lança-perfume". Em se tratando de flagrante delito, o ato dos guardas municipais foi legítimo, conforme previsão do artigo 301, do Código de Processo Penal: "Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". Neste sentido: "Embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, §8º, da Constituição da República, sendo delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão dos objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator, nos termos do artigo 301, do CPP" (STJ, HC 109.592/SP, 5ª T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18-2-2010, DJe de 29-3-2010). Outrossim, no recente julgamento das ADIs 5948 e 5538, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucionais as vedações trazidas pelo Estatuto do Desarmamento ao porte de armas por guardas civis, reiterando que estes executam atividade de segurança pública essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade. E, no plano legislativo, a Lei 13.675/2018 indica as Guardas Municipais como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública. Conclui-se, pois, que embora a atividade precípua das Guardas Municipais seja a proteção dos bens e serviços do município, bem como do patrimônio público, não há impedimento a que em situações específicas seus integrantes colaborem com a repressão à criminalidade, elevando, por óbvio, a segurança dos municípios. Ademais, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (...)", hipótese dos autos" (TJ/SP, Apelação Criminal nº 1500107-33.2022.8.26.0540, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, julgado em 29.04.2022).

Observe-se, assim, que o depoimento prestado em juízo pelo guarda municipal, além de plenamente coerente, está em perfeita harmonia àquele por ele prestado perante a autoridade policial. Ademais, não há qualquer motivo a que não possa ser atribuído total crédito a tais depoimentos. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que os guardas civis tivessem motivo particular, injusto, para incriminar falsamente a ré.

Além disso, a quantidade de droga encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a variedade e a forma em que era transportada, o local da abordagem, conhecido ponto de tráfico, além do dinheiro apreendido, trazem elementos suficientes de que a ré, em comparsaria com o corréu Fernando, tinha a droga para entrega a terceiros.

Dessa forma, entendo que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixa-se a pena-base da ré em 1/6 acima do mínimo legal em razão da quantidade de drogas apreendidas – 250 porções de cocaína (283g), 572 de crack (313,7g), 272 de maconha (557,6g), 07 de ecstasy (08g) e 45 frascos de lança perfume (900ml), fator que justifica a majoração da reprimenda penal, na medida em que incrementa o potencial ofensivo à saúde pública (bem jurídico tutelado pela norma penal), revelando uma maior reprovabilidade da conduta dos agentes (STF, HC 73.097, rel. Min. Maurício Corrêa, HC nº 76.543-5, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC nº 35.539, rel. Min. Paulo Medina, HC nº 35.795, rel. Min. Nilson Naves, HC nº 35.159, rel.

Min. Hamilton Carvalhido), perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Quanto ao potencial lesivo da quantidade de cocaína e "crack" apreendida:

"A cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes inesperadamente com pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2 g para um homem de 70 kg. No entanto, fumadores de base livre reportam uso de quantidades que excedem a 1 g. Em contrapartida, há casos em que se pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de 20 mg. Isto pode ser explicado pela ocorrência da tolerância reversa que se caracteriza ou pelo aumento da susceptibilidade ao aparecimento de convulsões em doses consideradas recreacionais ou por uma excitação aumentada obtida em doses menores em usuários crônicos, fato que pode ser explicado pela diminuição da biossíntese dos neurotransmissores, o que leva a uma potencialização dos efeitos excitatórios." (Passagli, Marcos; Toxicologia Forense – Teoria e Prática, 5ª ed., Millennium: Campinas, 2018 – pg. 180-1).

Na segunda fase, diante da menoridade relativa da ré, sua pena retorna ao patamar mínimo, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi presa em flagrante na posse das substâncias entorpecentes, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos. Não fosse suficiente, o presente decisor sequer referiu-se ao interrogatório da ré, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recruto de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobeja seria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense. Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a princípio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

“CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real”. (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: “Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é *contradictio in terminis*, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça”.

Na mesma direção, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

"[...] Não assiste razão ao apelante quando pleiteia o benefício da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, III, "d", do Código Penal, pois, no caso de que se trata, a confissão, além de absolutamente prescindível para o desate condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, bem revelando hábil manejo de autodefesa para tentada incidência da atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal. Assim, por não espontânea e desacompanhada de arrependimento, não permitiria a diminuição da pena pela atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Nesse sentido, "espontânea é aquela confissão em que o agente, independentemente do concurso da autoridade, busca esta para admitir o delito" (Apelação nº 0001496-21.2009.8.26.0270. Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 26.6.2012). No mesmo sentido: veneranda decisão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 0052302-70.2011.8.26.0050. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 16.4.2013). Da mesma forma: STF HC. nº 101.861/MS, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 13.4.2011). No mesmo sentido: PROVA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA - DISTINÇÃO. "Não se pode confundir a confissão espontânea com a confissão voluntária do réu surpreendido em plena execução do delito. Esta é uma declaração movida por uma circunstância de evidência dos fatos, aquela pela mera intenção de declarar a verdade". (Apelação nº 566.425/1, Julgado em 01/02/1990, Col. 1ª Câmara, Rel.: ALBERTO MARINO. RJDTACRIM 5/169)" (TJSP; Apelação Criminal 1501404-12.2021.8.26.0540; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022). g.n.

"(...) Afasta-se o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão. Isso porque Paulo foi preso em flagrante vendendo drogas a um adolescente e outro indivíduo, de modo que sua confissão não foi utilizada para formação da convicção. O flagrante e os depoimentos das testemunhas são suficientes para sustentar sobremaneira o édito condenatório." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500902-44.2018.8.26.0616,,

rel. Des. Roberto Porto, j. 18.6.2020, V.U.).g.n.

"(...) Ademais, sobreleva registrar que a referida confissão não foi utilizada pelo magistrado sentenciante como elemento de convicção, não incidindo, assim, na hipótese, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Veja que, para o reconhecimento da finalidade mercantil da droga apreendida com o acusado, o douto juiz não utiliza de sua confissão a esse respeito, mas sim dos demais elementos de convicção colhidos." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500646-88.2020.8.26.0630, rel. Des. Camilo Léllis, j. 22.3.2022, V.U.). g.n.

Apelação criminal - Tráfico de drogas - [...] Dosimetria - pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência. Confissão que não foi considerada na formação do convencimento do julgador. [...] Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido. "[...] verificando-se que neste caso, não houve qualquer menção ao teor do interrogatório do acusado para a formação do convencimento do douto Julgador para o deslinde desta ação penal, não há como se acolher o pleito de consideração da referida atenuante de pena, nos termos dos abalizados entendimentos jurisprudenciais referidos." (TJSP; Apelação Criminal 1500255-44.2022.8.26.0540; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2022; Data de Registro: 08/05/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo comprovada pela prova pessoal - Desnecessidade de apreensão e perícia da arma usada no roubo. (...) Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto não utilizada para fundamentar a condenação - Aumento único no concurso de causas de aumento de pena contemplado no parágrafo único do artigo 68 do Estatuto Penal que não constitui direito subjetivo, tratando-se de faculdade judicial, que, porém, requer justificativa sobre a fração imposta, como no caso penas e regime prisional fechados mantidos. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500106-76.2021.8.26.0348, Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni, j. 12.04.22).

"Descabe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da precisa fundamentação exarada pelo d. Juiz sentenciante: "Justifica-se, na segunda etapa, a não incidência da atenuante da confissão, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão, não espontânea, de quem foi preso em flagrante na posse do objeto subtraído, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos. Não fosse suficiente, o presente decisor sequer referiu-se ao interrogatório do réu, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ".(TJSP, Apelação Criminal nº 1502274-57.2021.8.26.0540, Rel. Des. JUSCELINO BATISTA, j. 23 de maio de 2022).

Não bastasse, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, recentemente:

"Agravamento regimental no habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Matéria não analisada na apelação. Óbice à inovação em sede de embargos de declaração. Constrangimento ilegal inexistente, Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça STJ. Édito condenatório apoiado em outros elementos. Não incidência. Precedentes. Agravamento regimental desprovido. 1. [...] 2. Ainda que controverso o fato de que o paciente assumiu a autoria do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. Conforme se verifica, a condenação está amparada no testemunho da vítima e dos policiais condutores da prisão, sendo portanto, inviável a redução da reprimenda. Precedentes, 3. Agravamento regimental desprovido (STJ AgRG no HC 648.216/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe, 15.06.2021).g.n

"A Súmula 545/STJ prevê que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. Evidenciado que a confissão informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal" (AgRg no AREsp 1599610/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020).

Ainda assim, a reprimenda não poderia ser conduzida aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Não deve incidir, no caso concreto, a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Não se desconhece que a quantidade do entorpecente, nos termos da Repercussão Geral no ARE nº 666.334/AM, rel. Min. Gilmar Mendes, deve ser ponderada em apenas uma das fases da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem.

Todavia, diante das demais circunstâncias do delito - Além da quantidade, a ré atuava em comparsaria, foi presa em flagrante com cinco espécies diversas de entorpecentes, notadamente "crack", em local conhecido como ponto de tráfico, sabidamente dominado por facções criminosas, portanto, sem espaço para "traficantes ocasionais estranhos à organização criminosa", além de não ter comprovado de forma mínima o exercício de atividade lícita- parece-me claro o acentuado envolvimento da acusada no comércio de drogas, ou seja, a não ocasionalidade da conduta.

Repita-se que, nesta etapa, não há bis in idem na valoração da quantidade de drogas, já que tal circunstância foi utilizada apenas supletivamente, conjugada com outros vetores do caso concreto, para o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Nessa linha, posiciona-se o e Superior Tribunal de Justiça:

"Não há bis in idem quando o Tribunal a quo fixa a pena-base acima do mínimo em razão da quantidade e natureza da droga apreendida e afasta o redutor do art. 33 § 4º da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa, que restou evidenciada pela quantidade e nocividade da droga apreendida (um quilo de maconha). Também não há bis in idem quando a quantidade e a natureza da droga são consideradas na primeira fase da dosimetria da pena e, logo depois, no momento da fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda" (STJ, AgRg no Resp 1690827 MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

No mesmo sentido o e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"(...) Frise-se, por oportuno, a inaplicabilidade do redutor especial inserto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tal como decido monocraticamente. Como cediço, ao editar o mencionado dispositivo legal, o legislador objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, representado por aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, conseqüentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual. Em outras palavras, para a situação do mercador novato de pequena expressão, o chamado "traficante de primeira viagem", como se pode qualificar aquele que possui "estoque" diminuto para negociar durante um curto período e, em regra, suprir o próprio vício é que a lei previu a benesse como forma de abrandar seu maior rigor punitivo. Nessa quadra, a par da primariedade, os elementos angariados aos autos demonstram, à saciedade, que as circunstâncias fáticas, concretamente recolhidas no

curso das investigações e comprovadas em Juízo, são inconciliáveis com a traficância ocasional. Isso porque, o réu foi flagrado transportando e guardando exacerbada quantidade de entorpecentes (247 porções de maconha, 406 pinos de cocaína e 438 porções de crack), com naturezas extremamente destrutivas e nocivas, suficiente a atingir inúmeros usuários, de sorte a evidenciar a dedicação às atividades criminosas (narcotraficância). Nem se cogite a ocorrência do intolerável bis in idem, pois a quantidade dos entorpecentes, muito embora sopesada na primeira fase da dosimetria penal, não foi aqui considerada de forma isolada para o afastamento do benefício legal, ao contrário, as circunstâncias fáticas do flagrante policial (o que inclui natureza, quantidade e diversidade dos entorpecentes, situação de fuga à abordagem, em ponto com denúncias reiteradas da traficância), em conjunto, evidenciam dedicação habitual à atividade criminosa, sendo absolutamente implausível o reconhecimento do privilégio." (Apelação Criminal nº 1500603-96.2021.8.26.0540, Rel. Des. CLÁUDIA FONSECA FANUCCHI, j. 13 de dezembro de 2021).

Ainda sobre o redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06:

"(...) Cabe salientar que 'a conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade da droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas', para os fins a que alude o citado artigo de lei (STF, RHC nº 94.806, relatora Ministra Cármen Lúcia). Na realidade, a qualificação do agente como pessoa dedicada às atividades criminosas situação que afasta a incidência da causa de diminuição de pena estampada no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006 pode vir assentada na prova indiciária, tal como esta se acha definida no artigo 239, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 155, do Código de Processo Penal), não se exigindo prova direta desta circunstância, sob pena de inviabilização da repressão penal a este tipo de delito, dada a dificuldade de se obter uma prova deste tipo (STF, HC nº 101.519, rel. Min. Luiz Fux). Consoante salientado pelo Ministro Luiz Fux, em passagem bastante elucidativa de seu voto, 'os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas'. Deveras, na interpretação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, há que se atentar para o elemento teleológico, na dicção do artigo 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil (FRANCISCO AMARAL, Direito Civil, Introdução, Renovar, 12 edição, pp. 88/89; JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, Introdução e Teoria Geral, Renovar, 2ª edição, pp. 430/431), vale dizer, no sentido de que o escopo da lei foi de beneficiar com uma sensível redução da pena aquele agente que pela primeira vez se lança no mundo criminoso, cuja conduta não representa um maior perigo para a coletividade, de sorte que a pena reduzida, ainda que considerada a gravidade do tráfico de entorpecentes, afigura-se suficiente para a ressocialização e reprove suficientemente o comportamento. Essa não é, decididamente, a situação dos réus." (TJSP, Ap nº 1501840-05.2020.8.26.0540, Des. Rel. LAERTE MARRONE, j. 28.04.21).

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. ANÁLISE DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE SER INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. [...] 3. A conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi

apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010. [...] (STF HC 121.057/SP Rel. Min. Luiz Fux j. 25.02.14 DJU 18.03.14).

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA, MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O §4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes dispõe a respeito da causa de diminuição da pena nas frações de 1/6 a 2/3 e arrola os requisitos necessários para tanto: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividades criminosas e não à organização criminosa. 2. Consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de ser utilizado mercê de, como visto, haver elementos fáticos conducentes a conclusão de que o paciente era dado à atividade delituosa. 3. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções 'hominis' ou 'facti', pelo juiz, para decidir sobre a procedência do 'ius puniendi', máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como 'a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias'. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugênio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 4. Deveras, o julgador pode, mediante um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 5. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. In casu, o Juízo de origem ponderou a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (1,82g de cocaína pura, 8,35g de crack e 20,18g de maconha), destacando a forma como estavam acondicionadas, o local em que o paciente foi preso em flagrante (bar de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. [...] 6. Os fatos que deram ensejo à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Tóxicos são hígidos e suficientes

para atestar a dedicação do Paciente às atividades criminosas. 7. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. [...] (STF HC 109.236/SP Rel. Min. Cármen Lúcia j. 13.12.11 DJU 14.23.12).

Estabiliza-se, assim, a sanção em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

O valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica da ré.

Anote-se que o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 44 da Lei 11.343/06, nas partes em que se vedava a concessão de liberdade provisória (HC n. 104.339, rel. Min. Gilmar Mendes) e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (HC n. 97,256, rel. Min. Ayres Britto), bem como do parágrafo 1º do art. 2º da Lei n. 8072/90, que impunha o regime inicial fechado (HC n 111.849, rel. Min. Dias Toffoli).

Todavia, a gravidade in concreto do delito, considerando a quantidade e diversidade das drogas, assim como o alto potencial lesivo da cocaína e do crack para saúde pública, indica um grau acentuado de culpabilidade, de forma que o regime inicial fechado mostra-se necessário para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. Possibilidade de fixar regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.Ordem denegada.” (STF - HC 119.515/AC - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 03.12. - DJU 10.12.13)

Pelo mesmo motivo, não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, insuficiente para prevenção e reprovação da conduta.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR a ré ANA BEATRIZ GOMES DUARTE, qualificada nos autos, a cumprir pena de 05 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Defiro o direito de recorrer em liberdade (fls.62-4 e 212-3).

Transitada em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella -Juiz de Direito

(assinado eletronicamente)

Mauá, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA